

1526071-28.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... permanente, habitual e estável para a prática do crime de tráfico de drogas. Não basta o mero cometimento de tráfico de entorpecentes por duas ou mais pessoas, já que "...é do nosso sistema penal (sem exceções) punir mero concurso de agentes como agravante, causa de aumento ou qualificadora de crime, jamais como tipo básico, um delito autônomo." (Lei de Drogas Comentada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1526071-28.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526071-28.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ MARCELINO MIRANDA DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

JOSÉ MARCELINO MIRANDA DE SOUSA e HENRIQUE SILVA DA CRUZ, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas dos artigos 33, "caput", c.c artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 27 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta, ainda, que no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 12h30, na Rua Antônio Scotti, 10, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, JOSÉ MARCELINO MIRANDA DE SOUSA e HENRIQUE SILVA DA CRUZ, agindo em concurso, em unidade de designios e conjugação de esforços, traziam consigo, para fins de tráfico, 82 porções contendo, aproximadamente, 61,5g de substância vulgarmente conhecida como "cocaína", 29 porções contendo, aproximadamente, 3,71g de substância vulgarmente conhecida como "cocaína" em forma de "crack", e 41 porções contendo, aproximadamente, 81,7g de substância vulgarmente conhecida como "cocaína", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 25,00 em espécie.

Os acusados, notificados nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, apresentaram Defesa Prévia, subscrita por Defensor constituído nos autos.

Recebida a denúncia (págs. 121/126), durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se ao final os réus. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na procedência integral da presente ação penal.

O Dr. Defensor, por sua vez, requereu a absolvição e sustentou, em síntese, precariedade probatória. Alternativamente, pleiteou : redução da reprimenda na fração máxima prevista em lei por força do que estabelece o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06; fixação de regime inicial diverso do fechado para início de cumprimento da pena; substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
D E C I D O.

É parcialmente procedente a presente ação penal.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 05 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 07/10); pelo auto de exibição e apreensão (pág. 26); pelo laudo de constatação (págs. 43/45); pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 89/91), que resultou positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol; bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, nas oportunidades em que foram interrogados, os acusados admitiram o cometimento do crime.

Narraram, em síntese, que enfrentavam dificuldades financeiras, o que os levou a praticar o crime.

HENRIQUE afirmou que na data em que foi preso portava a sacola contendo as drogas, e que recebia a quantia de R\$1,00 por entorpecente vendido. Havia começado a traficar pela manhã, por volta das 9h00, mas acabou surpreendido e preso por policiais poucas horas depois.

Acrescentou que JOSÉ MARCELINO realizava a função conhecida por olheiro, mas foi o primeiro dia que venderam drogas juntos.

Por fim, disse que foi o segundo dia que se pôs a vender os entorpecentes, e que na véspera o corréu não estava em sua companhia, e sua função foi fiscalizar o local.

JOSÉ MARCELINO, da mesma forma, admitiu que estava no local acompanhado do corréu e juntos vendiam as drogas, o que vinha fazendo há poucos dias.

Esclareceu que ganhava a quantia diária de R\$70,00 para exercer referida atividade ilícita.

Ambos justificaram que estavam desempregados, por essa razão enfrentavam dificuldades financeiras e mostraram-se arrependidos.

Referidas confissões se ajustaram aos elementos de convicção produzidos no

contraditório.

Os policiais civis inquiridos apresentaram esclarecimentos coerentes e harmônicos a respeito da diligência que realizaram.

Informaram que o local é notório ponto de venda de drogas. Patrulhavam pela região e notaram a movimentação suspeita de ambos os réus, que estavam juntos, HENRIQUE segurava uma sacola, ao passo que JOSÉ MARCELINO estava ao lado dele e mostrava-se atento ao que ocorria no entorno.

Diante desse comportamento característico de traficantes, realizaram breve campana, oportunidade em que puderam observar o vínculo estabelecido entre os réus, uma vez que HENRIQUE se posicionou encostado em uma parede, segurando uma sacola plástica, ao passo que JOSÉ MARCELINO se movimentava e observava o local, e ambos se comunicavam.

Desta forma, optaram pela abordagem e lograram localizar as drogas diversificadas e fracionadas, bem como a quantia em dinheiro em poder de HENRIQUE, mais precisamente no interior da sacola que estava em poder dele. JOSÉ MARCELINO não portava qualquer substância ilícita, mas ambos admitiram que promoviam a mercancia no local, sendo que este último exercia a função conhecida por "olheiro".

Diante desses fatos, deram voz de prisão aos réus e os conduziram ao distrito policial.

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do crime e responsabilidade dos acusados pelo tráfico de drogas.

Assim é que ambos os acusados admitiram que promoviam a mercancia no local, mostraram-se arrependidos e justificaram que enfrentavam dificuldades financeiras.

E os policiais civis ouvidos, de forma serena e insuspeita, deram conta da diligência que realizaram, motivada por comportamento suspeito dos acusados, que estavam juntos em notório ponto de venda de drogas. Esclareceram que depois que realizaram breve campana, optaram por abordar os réus e lograram localizar grande quantidade de drogas diversificadas em poder deles.

Por esses argumentos, não há que se falar em prova precária e não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa.

E, a versão apresentada pelos policiais, é digna de toda credibilidade, uma vez que não existe demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente. Como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentaram só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas".(TJRJ - AC - Rel Synésio de Aquino - RDTJR 7/287). Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação.

O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

As inúmeras porções de entorpecentes localizadas em poder e sob responsabilidade dos réus, ou seja, : 82 porções contendo, aproximadamente, 61,5g de substância

vulgarmente conhecida como "cocaína", 29 porções contendo, aproximadamente, 3,71g de substância vulgarmente conhecida como "cocaína" em forma de "crack", e 41 porções contendo, aproximadamente, 81,7g de substância vulgarmente conhecida como "cocaína", revelam que as drogas seriam vendidas, de forma que não é o caso de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei Especial.

Ademais, nem mesmo os réus reivindicaram a posse da totalidade das substâncias para consumo próprio. Muito pelo contrário, admitiram que estavam promovendo a mercancia no local em que foram surpreendidos, já conhecido pela ocorrência dessa atividade criminosa.

Não obstante, a absolvição dos réus é de rigor com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Não há nos autos prova do animus associativo, elemento constitutivo do tipo penal em questão, ou seja, de que os acusados estavam associados em caráter permanente, habitual e estável para a prática do crime de tráfico de drogas. Não basta o mero cometimento de tráfico de entorpecentes por duas ou mais pessoas, já que "...é do nosso sistema penal (sem exceções) punir mero concurso de agentes como agravante, causa de aumento ou qualificadora de crime, jamais como tipo básico, um delito autônomo." (Lei de Drogas Comentada, coordenação Luiz Flávio Gomes, 2ª edição, fls. 207).

Os policiais narraram que foi a primeira vez que surpreenderam os acusados juntos vendendo drogas. E os esclarecimentos prestados pelos denunciados na fase policial não se mostraram suficientes, por si só, para caracterizar a estabilidade exigida pelo tipo penal em questão.

Logo, pela ausência de provas a respeito da ocorrência do crime referido, a dúvida formada determina a solução absolutória.

Desse modo, demonstrada a ocorrência do tráfico de entorpecentes praticado pelos denunciados, a parcial procedência da ação penal é de rigor.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Ao que consta ambos os réus são primários e não registram outros envolvimento criminais.

Desta forma, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Incidu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumprе salientar, que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 - circunstância objetiva -, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social. Ademais, os acusados praticaram crime que compromete a saúde pública, já extremamente abalada pela pandemia.

Todavia, referida agravante fica compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Considerando a primariedade dos réus e a quantidade de drogas apreendidas, é o caso de aplicação do que dispõe o artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, daí porque diminuo a pena à razão de 1/3, o que resulta em definitivo em três anos e quatro meses de reclusão e trezentos e trinta e quatro dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal

Justifico a aplicação da fração intermediária, uma vez que os réus portavam drogas diversificadas, boa parte cocaína, substância altamente nociva e viciante. A quantidade apreendida foi significativa, o entorpecente estava fracionado em inúmeras porções individuais, e os réus estavam ajustados e vendiam as drogas em notório ponto de venda de drogas. Ademais, não foi a primeira vez que exerceram referida atividade criminosa, como eles próprios informaram.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra JOSÉ MARCELINO MIRANDA DE SOUSA, R.G. nº 44.582.138, e HENRIQUE SILVA DA CRUZ, R.G. nº 54.647.817, e os condeno, cada um, ao cumprimento de três anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a trezentos e trinta e quatro dias-multa, ambos por infração ao artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06; e os absolvo da imputação do artigo 35 da mesma lei, fazendo-o com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista a pena aplicada, bem como as peculiaridades do caso, réus primários, que confessaram o cometimento do crime, por se tratar de medida socialmente recomendável, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada para cada um dos réus pela restritiva de direitos, na forma de prestação de serviços a comunidade, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais e mais dez dias multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Em caso de revogação o benefício, o que justifico pelas razões expostas quando da aplicação do redutor de pena, fixo o REGIME ABERTO para início de cumprimento da privativa de liberdade aplicada.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Nos termos dos artigos 62 e seguintes da Lei 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em dinheiro relacionada no auto de exibição e apreensão - R\$25,00 - (pág. 26), uma vez que oriunda do comércio ilícito que os acusados promoviam no local onde foram surpreendidos pelos policiais civis.

Após o trânsito em julgado, sejam os nomes dos réus lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA